

1. 判决书字号

江苏省扬州市中级人民法院(2023)苏10刑终59号刑事裁定书

2. 案由：假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪

【基本案情】

2018年11月至2020年1月，被告人张某未经“A”品牌注册商标权利人许可，由某化妆品公司负责提供所需雪花膏原料，由被告人张某将印有“A”品牌注册商标的雪花膏配套包装(包含玻璃瓶、瓶盖、内垫、彩盒、中箱等)交由某化妆品公司完成灌装、包装等工作。2020年1月至2021年3月，被告人张某、被告单位某化妆品公司实际经营人韩某某共同计议采用上述手段假冒“A”品牌注册商标，被告单位某化妆品公司以每瓶收取1.8元加工费的手段非法获利3.6万余元。被告人张某将以上代加工的假冒“A”品牌注册商标的雪花膏成品以7.8元/瓶的价格销售给被告人林某，销售金额合计17.7万余元，其中2020年1月至2021年3月销售金额共计15.8万余元。2021年4月22日，某县公安局在被告人张某住宅处，现场查获并扣押假冒“A”品牌注册商标的雪花膏等物品。

2018年11月至2021年3月，被告人林某明知印有“A”品牌注册商标的雪花膏为假冒注册商标的商品，仍以7.8元/瓶的价格从被告人张某处进购规格为100毫升的假冒“A”注册商品的雪花膏，后以11元/瓶的价格通过微信联系、他人代发货等手段销售给被告人黄某22786瓶，销售金额合计25万余元，非法获利7.3万余元。

2018年12月至2021年3月，被告人黄某明知印有“A”品牌注册商标的雪花膏为假冒注册商标的商品，仍以11元/瓶的价格从被告人林某处进购，后以12元/瓶的价格通过本人经营的位于某批发市场某百货柜台销售给被告人胡某22774瓶，销售金额合计27.3万余元，非法获利2.2万余元。2021年3月12日，某县公安局在被告人黄某经营的商店内，现场查获并扣押假冒“A”品牌注册商标的雪花膏12瓶。

2020年1月至2021年3月，被告人胡某明知印有“A”品牌注册商标的雪花膏为假冒注册商标的商品，仍以12元/瓶的价格从被告人黄某处进购，并通过本人经营的网络店铺销售20329瓶，销售金额合计人民币31.9万余元，非法

获利4.6万余元。2021年3月10日，某县公安局在被告人胡某住宅内，现场查获并扣押假冒“A”品牌注册商标的雪花膏29瓶。

2020年5月至2021年1月，被告人彭某明知印有“A”品牌注册商标的雪花膏为假冒注册商标的商品，仍从被告人胡某处进货，并通过其本人经营的网络店铺销售至各地，销售金额合计人民币20.4万余元。2021年1月26日，某县公安局在被告人彭某住宅处，现场查获并扣押假冒“A”品牌注册商标的雪花膏等物品。

经比对，从买家处调取以及扣押的物品上标有的“A”注册商标与注册商标权利人注册商标构成相同。经注册商标权利人确认，系假冒“A”注册商标的商品。

【案件焦点】

1. 单位负责人检举的与单位生产经营无关联性的他人犯罪，是否应认定为单位立功；2. 被告单位某化妆品公司、被告人韩某某的非法经营数额如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省高邮市人民法院经审理认为：被告人张某、被告单位某化妆品公司未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，被告人韩某某作为被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成假冒注册商标罪，且部分犯罪属共同犯罪；被告人林某、黄某、胡某销售明知是假冒注册商标的商品，具有其他严重情节，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪；被告人彭某销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。据此，根据《中华人民共和国刑法》第十二条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第二百一十三条、第二百一十四条、第二百二十条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人张某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；

二、被告单位某化妆品公司犯假冒注册商标罪，处罚金人民币8万元；

三、被告人韩某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5万元；

四、被告人林某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币14万元；

五、被告人黄某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；

六、被告人胡某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；

七、被告人彭某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币11万元；

八、公安机关扣押的假冒注册商标的商品及作案用电脑，依法予以没收；扣押的被告人张某退出人民币45万元依法折抵罚金刑10万元，余款35万元发还给被告人张某；扣押的被告单位某化妆品公司、被告人韩某某退出的人民币20万元依法没收违法所得36000元、折抵罚金刑13万元，余款34000元发还给被告单位某化妆品公司、被告人韩某某；扣押的被告人林某退出的人民币21万元依法没收违法所得人民币73000元，余款137000元依法折抵罚金刑；扣押的被告人黄某退出的人民币19万元，依法没收违法所得22000元、折抵罚金刑5万元，余款118000元发还给被告人黄某；扣押的被告人胡某退出的人民币19万元依法没收违法所得46000元、折抵罚金刑10万元，余款44000元发还给被告人胡某；扣押的被告人彭某退出的人民币9万元依法折抵罚金刑；其余物品由公安机关依法处理。

一审宣判后，韩某某提出上诉。江苏省扬州市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

司法实践中，单位立功的认定较为少见。本案审理过程中，争议焦点在于单位负责人韩某某检举的与单位生产经营无关联性的他人犯罪，是否应认定为单位立功及某化妆品公司和韩某某犯罪金额的认定。

一、单位可以成立立功

自首和立功是我国惩治与宽大相结合的刑事政策在立法中的具体体现。根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第六十八条规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。

《刑法》规定立功的主体是“犯罪分子”，单位能否构成立功目前没有明确的规定。单位是一种人格化的社会组织，单位犯罪中直接责任人员的犯罪行为，实质上是单位的整体行为及单位意志的外在表现。单位既然能够通过其成员来形成犯罪决意和实施犯罪行为，同样也可以通过其成员来实施犯罪行为。刑法中虽未明确规定单位为立功的主体，但从确立单位犯罪的逻辑结果来看，对单位应同样适用立功这一法定从宽情节。^①

二、某化妆品公司不构成单位立功

与个人立功相比，单位立功有共性，也有其特殊性。共性在于不论是单位或个人都需要符合立功成立的要件要求，特殊性在于单位为拟制的人，仅具有法律拟制的人格，其行为必须通过自然人来实现，因此，单位立功的具体行为还须由具体的自然人予以实施。单位犯罪中，并非所有的个人立功当然地惠

及于单位，个人的立功行为必须能够代表单位的意志，为了单位的利益，符合单位的特征，单位才拟能够构成立功。^②

具体到本案，某化妆品公司实际经营人被告人韩某某检举他人毒品犯罪行为

①杨温蕊：《单位构成立功及其认定标准》，载《人民司法(案例)》2016年第14期。

②李翔：《单位犯罪司法实证研究——我国单位犯罪制度的检视与重构》，上海人民出版社2016年版，第114~119页。

为，但该检举线索并非单位掌握且亦非根据被告人韩某某的职务行为所掌握，该个人立功行为无法体现单位意志，在利益追求上与单位没有强烈的一致性，故被告单位某化妆品公司不具有立功表现，不构成单位立功。

三、某化妆品公司和韩某某犯罪金额的认定

根据法律规定已销售侵权产品的价值应当以实际销售的价格计算。被告人韩某某与张某共同商议，由被告单位某化妆品公司为被告人张某生产假冒注册商标的商品，被告单位通过收取加工费的方式非法获利，被告单位某化妆品公司与被告人张某构成共同犯罪，应当以被告人张某销售的假冒注册商标的商品的价格认定本案被告单位某化妆品公司及被告人韩某某的非法经营为15.8万余元。被告单位某化妆品公司提供雪花膏膏体并利用被告人张某提供的外壳、包装等物品生产假冒注册商标的商品的行为在假冒注册商标犯罪中与被告人张某的地位、作用相当，无须区分主、从犯，故某化妆品公司和韩某某非法经营数额不应以收取的加工费3万余元认定，而应该认定为15.8万余元。

综上，在认定单位立功时，要从是否体现单位意志、如何体现单位意志、是否履行工作职责等方面来综合认定。

编写人：江苏省高邮市人民法院 虞亚春 崔义敏

(三) 数罪并罚

46

漏罪发现的时间可以客观证据存在时间为标准

—— 张某贩卖毒品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省安吉县人民法院(2022)浙0523刑初342号刑事判决书

2. 案由：贩卖毒品罪

【基本案情】

被告人张某在2018年先后贩卖毒品六次，其中三次被安吉县人民法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑三年四个月，于2021年11月26日刑满释放。2022年张某因醉酒驾驶机动车被安吉县交警大队当场查获。案件侦办过程中，公安机关又发现张某剩余3次贩卖毒品的事实，同步立案侦查。后安吉县人民检察院指控张某犯贩卖毒品罪、危险驾驶罪，诉至安吉县人民法院。法院经审理查明：

1. 2018年2月22日，被告人张某以“埋地雷”的交易方式向郑某与周某贩卖甲基苯丙胺1次，贩卖甲基苯丙胺克数约为0.3克，获取毒资400元。

2. 2018年3月6日，被告人张某以“埋地雷”的交易方式向郑某与周某贩卖甲基苯丙胺1次，贩卖甲基苯丙胺克数约为0.3克，获取毒资400元。

3. 2018年4月1日，被告人张某以“埋地雷”的交易方式向郑某与周某贩卖甲基苯丙胺1次，贩卖甲基苯丙胺克数约为0.3克，获取毒资500元。

毒资支付方式均先由郑某向周某微信转账，再由周某向被告人张某微信支付。张某将甲基苯丙胺分别放置于安吉县某小区、某卫生院等地，贩卖克数约0.9克，获取毒资共计1300元。

【案件焦点】

张某剩余三次贩卖毒品的交易记录已在前罪贩卖毒品罪中被公安机关通过调取证据的方式调取，并作为证据固定入卷。此时，后罪能否适用漏罪的情形与前罪予以并罚。

【法院裁判要旨】

浙江省安吉县人民法院经审理认为：被告人张某违反国家毒品管制规定贩卖毒品，构成贩卖毒品罪。张某违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶汽车在道路上行驶，构成危险驾驶罪。张某一人犯数罪，应数罪并罚。张某贩卖毒品罪犯罪事实在前罪贩卖毒品罪案件中已被公安机关发现，证据亦被固定，系漏罪，应把前后判决所判处的刑罚予以并罚。据此，浙江省安吉县人民法院以贩卖毒品罪判处张某有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5000元。与前罪贩卖毒品罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币4000元并罚；以危险驾驶罪判处张某拘役一个月十日，并处罚金人民币1000元。决定对张某执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币1万元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于张某剩余三次贩卖毒品的交易记录已在前罪贩卖毒品罪中被公安机关通过调取证据的方式调取，并作为证据固定入卷。此时，后罪能否适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，漏罪的情形与前罪予以并罚。应回归法条本身进行分析。

一、漏罪的“发现”主体是认定基础

关于《中华人民共和国刑法》第七十条中对于发现漏罪的主体，
实务中存

在不同声音。部分观点认为，发现漏罪应以法院的判决为准，因条文中明确写明了发现“其他罪没有判决的，应对新发现的罪作出判决”，此时的适格主体只有人民法院。更多观点认为，主体应是最早发现漏罪的司法机关(绝大多数情况下系公安机关)，即“最早发现说”。实践中，“最早发现说”已成为一种共识，漏罪的处理需要经历公检法多个环节，很可能在被告人前罪刑罚执行完毕后，后罪才诉至法院，此时再成立发现的节点已不再符合发现漏罪的标准，势必会造成法条前后相矛盾的情形。而要成立“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前”的条件，唯有以公安机关发现漏罪锁定犯罪嫌疑人的时间点最为符合立法本意。本案中，公安机关在侦办张某危险驾驶罪案中，发现了张某还存在贩卖毒品罪的情形，一并移送检察机关审查起诉，将公安机关作为漏罪的发现主体，为本案之后的评判打下基础。

二、“发现”漏罪的主客观性分析

有观点认为，漏罪的发现时间应以公安机关在侦查过程中主观上发现漏罪证据，进而锁定犯罪嫌疑人为标准。但从立法本意上看，发现并非只能作动词解释，也可作名词解释，即不必然要求公安机关主观上发现漏罪，由此对《中华人民共和国刑法》第七十条中的“发现”应作更加宽泛性的理解。特殊情况下，公安机关在侦办前罪时客观上收集了漏罪的证据并通过立案侦查的方式将其固定，即使主观上并未发现，只要该部分并未作为前罪的定罪依据，那么在收集程序合法，内容客观公正，已形成法律真实，能够证明漏罪犯罪事实的情况下，就可以将漏罪的“发现”时间提前到该部分证据客观存

在的时间，由此便可适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定。并且，该证据的证明力并不用达到充分的程度，只要作为破开漏罪大门之匙，再得到进一步侦查即可。回归到本案，前罪中公安机关调取了张某贩卖毒品时期的交易记录，并刻录成光盘固定，后结合其他证据形成完整证据链，从而定罪量刑。后罪中认定张某贩卖毒品的主要证据为二名吸毒人员的证人证言以及他们与张某间微信互相转账的三次交易记录，而这三次记录恰恰存在于前罪固定的光盘中。虽然张某始终未如实供述犯罪事实，公安机关亦未在前罪刑罚执行完毕前认定该罪行，但

该三次转账记录已存在于前罪侦查阶段固定的证据中，且能证明罪行的存在。不影响本案适用《中华人民共和国刑法》第七十条关于漏罪情形的规定。

三、本案可依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定适用数罪并罚

在刑罚执行完毕前发现的漏罪，若是同种漏罪，通常合并审理按一罪处罚，当以一罪论处明显违反罪责刑相适应原则时，则按数罪并罚。若是异种漏罪，则实行数罪并罚。在刑罚执行完毕后发现漏罪，应单独定罪处罚。以上是实践中的通常做法。但本案漏罪具有特殊性，系前罪判决宣告以前漏罪已被“发现”但并未处理，在前罪刑罚执行完毕后，漏罪才被诉至人民法院。实践中也遇到因异地办案、侦破复杂等特殊原因导致漏罪移送时而前罪刑罚已执行完毕的情形，这是立法者没有预见到的。对于该种漏罪，仍然可以适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定实行数罪并罚。《中华人民共和国刑法》第七十条所规定的判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪的并罚是依照刑法第六十九条判决宣告前一人犯数罪的并罚实行的。而本案实施数罪并罚从法理上并未超出两个法条的界定，在刑期上依然适用“先并后减”，也确保了罚当其罪。

回归本案，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，向多人贩卖毒品的属于贩卖毒品罪中“情节严重”的情形，应处三年以上七年以下有期徒刑。前罪以张某贩卖毒品三次判处有期徒刑三年四个月，后罪以张某贩卖毒品三次判处有期徒刑三年一个月，前后罪单看

法条 运用均符合法律规定，若机械性照搬法条文字而直接将后罪单独处置，势必会 导致量刑失衡。此种情形下，对张某适用《中华人民共和国刑法》第七十条的 规定实行数罪并罚，在吸收危险驾驶罪的拘役刑后，决定的宣告刑为四年四个月，扣除前罪已执行的三年四个月后，实际执行刑期为一年。实质效果上不仅 与《中华人民共和国刑法》第六十九条规定无差别，法律意义上更体现了数罪 并罚限制加重原则的立法本意。

编写人：浙江省安吉县人民法院 陈喻

前罪因客观原因未处理，
后罪刑罚执行完毕后又犯与前罪同种罪名之新罪，
未处理前罪与所犯新罪应作一罪处理

——徐某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省太仓市人民法院(2023)苏0585刑初660号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

被告人徐某某前科犯罪具体案发及审理经过：2017年5月至同年8月，被告人徐某某以帮请律师打离婚官司、办理投资理财等借口，骗取被害人周某某钱款162155.55元、谢某某钱款60829.56元、郑某某钱款64900元。被害人谢某某、郑某某、周某某等人先后于2017年8月27日、10月19日、11月22日报案至某市公安局，某市公安局先后于2017年8月28日、10月22日、11月22日立案进行侦查。某市公安局在侦查过程中发现，被告人徐某某在异地涉嫌盗窃罪，被某区公安局立案侦查。故某市公安局发函至某区公安局并将被告人徐某某涉嫌诈骗罪的相关材料一并移送某区公安局，希望该局对被告人徐某某涉嫌诈骗罪一案并案处理。因两家公安机关之间的案件移送及协调问题，某区公安局仅侦查了被告人涉嫌盗窃罪一案，对于某市公安局移送的被告人涉嫌诈骗罪一案并未处理。2018年12月，被告人徐某某因盗窃罪被山东省济南市槐

荫区人民法院判处有期徒刑一年，2019年4月29日刑满释放。

后某市公安局知晓其向某区公安局移送的被告人徐某某涉嫌诈骗罪一案，某区公安局并未处理，故某市公安局又继续侦查。在此期间，即2022年10月至11月，被告人徐某某以被害人郑某身上有“狐仙”，需要办理投资理财才能消灾为由，骗取被害人郑某89339.01元。被告人徐某某因涉嫌诈骗罪于2023年6月20日被抓获归案。案发后，被告人徐某某已赔偿被害人谢某某损失人民币60000元。2023年9月12日，江苏省太仓市人民检察院以被告人徐某某犯诈骗罪，向江苏省太仓市人民法院提起公诉。

【案件焦点】

判决宣告前犯有数罪，但因客观原因仅处理了其中一罪且该罪刑罚已执行完毕，后被告人又犯与此前未被处理罪名之同种新罪，应作一罪处理还是数罪并罚。

【法院裁判要旨】

江苏省太仓市人民法院经审理认为：被告人徐某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐某某系累犯，应当从重处罚。被告人徐某某自愿认罪认罚，对此予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：

一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币66000元；

二、责令被告人徐某某在本判决生效后一个月内退出非法所得人民币317224.12元，分别发还被害人。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案核心在于，判决宣告前犯有数罪但仅处理一罪，后又犯新罪，未处理

犯罪与所犯新罪系同种犯罪，应数罪并罚还是作为一罪处理？就此，笔者逐层分析如下。

一、未被处理的犯罪能否认定为漏罪

《中华人民共和国刑法》第七十条规定：“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。”根据该法条文义理解，漏罪的发现时间区间在“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前”，该处的“发现”似乎已经在实践中形成统一的法律内涵，即无论是通过他人揭发、犯罪分子主动交代，还是办案机关主动侦查等途径，都应被司法机关知晓并至少已经掌握初步的犯罪事实，时间一般以公安机关的立案时间为发现时间。那么，关于“漏罪”的时间节点，如果超出这个时间边界应当如何适用。例如，判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现漏罪，但漏罪判决作出时前罪原判刑罚已经执行完毕，是否会影响漏罪的界定？判决宣告以前，就发现被告人还犯其他罪的，能否定为漏罪？

本案中，被告人所犯诈骗罪与盗窃罪是同时期发现，因为工作协调问题仅处理了被告人的盗窃罪，也即未处理的诈骗罪发现的起点为盗窃罪“判决宣告以前”，此种情况下未处理的罪能否视为漏罪。实践中也存在争议，一种观点认为，“判决宣告以后”发现即可以作为漏罪进行并罚，按照举重以明轻的原则，判决宣告以前发现的更应该作为漏罪进行处理，应当使用刑法第七十条关于漏罪并罚的规定进行处理；另一种观点

认为,《中华人民共和国刑法》第七十条明确了发现漏罪的时间节点,“判决宣告以前”在文义上超出了法条用语的边界,不能适用。笔者赞同第二种观点,理由如下:其一,第一种观点超出了刑法用语的范围,虽然在刑法理解上要有利于被告人,但这种原则在适用时不能过分延伸;其二,被告人在前罪判决时并未如实供述其还有其他犯罪的情况,应当由其自行承担不利法律后果。因此,本案被告人未被处理的诈骗罪不应作为漏罪处理。

二、未处理的犯罪与所犯新罪系同一罪名的处理

本案中，被告人在盗窃罪判决宣告以前已经实施了诈骗犯罪，且已被侦查机关发现，但由于工作协调的问题，迟迟未予处理。后被告人在盗窃罪判决宣告以后且刑罚执行完毕后又实施新的诈骗犯罪。该种情况下，应如何判处。实践中，存在两种意见：一种意见认为，按照两个罪进行数罪并罚；另一种意见认为，未处理的罪与新罪系同种罪名，应作为一罪进行处理。笔者赞同第二种意见，理由如下：其一，被告人所犯盗窃罪与所犯诈骗罪同时期被发现，因为侦查机关工作协调问题，被告人所犯诈骗罪无法认定为漏罪，无法进行数罪并罚。若定为两罪再进行数罪并罚，对于被告人来说并不公平。其二，被告人所犯诈骗罪虽已被发现，但并未侦破也未移送起诉，在此期间被告人再犯同种罪的，作为一案处理并无不当，亦能够做到罪责刑相适应。

编写人：江苏省太仓市人民法院 吴守花 马李莎

在被假释以前发现漏罪，但在假释考验期限内
被采取刑事强制措施的，仍应当撤销假释

——侍某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2020年7月，被告人侍某某及程某、蒯某等人经合意在A 国地区成立电信

诈骗组织，采取“杀猪盘”诈骗等方式骗取中国境内公民钱财。被告人侍某某对公司整体运作负责管理、对接洗钱等，蒯某对公司后台进行管理并负责财务等，程某同时担任主管，负责公司的运营、督促业绩、指导各组工作。该诈骗组织招募姚某、张某等人担任代理、组长；招募姚某1、俞某等几十人为业务员。该组织内代理负责招募业务员并管理组长，组长负责培训业务员，管理业务员的工作和日常生活；业务员负责在交友软件上冒充成功男士结交国内女性被害人，按照话术与对方聊天、谈恋爱，获取被害人的信任后将对方诱导至公司控制的“区块链”平台上投资，再由组长、主管等管理人员接手聊天继续诱导被害人在“区块链”平台上充值，并在被害人加大投资后采用操控后台使其亏损、限制其提现的手段骗取被害人钱款。被告人侍某某从中非法获利人民币3万元。2020年11月下旬，被告人侍某某及程某、蒯某等人离开诈骗组织，由姚某、许某、王某三人接手，采取上述相同手段继续运营该诈骗组织。

被告人侍某某自愿退出违法所得人民币3万元。

另查明，被告人侍某某因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月22日被刑事拘留，2021年3月12日因犯诈骗罪被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑二年三个月（刑期自2021年2月22日起至2023年5月21日止），并处罚金人民币2万元（已缴纳）；2022年10月17日被浙江省衢州市中级人民法院裁定予以假释，同月21日假释释放，假释考验期限自2022年10月21日起至2023年5月21日止。某市公安局于2022年2月通过侦查明确被告人侍某某为本案犯罪嫌疑人，同年11月8日将被告人侍某某抓获并对其刑事拘留。

再查明，2021年4月至6月，姚某、俞某先后通过诈骗结识的陈某，明知上线转移的资金系网络犯罪所得，仍提供陈某的银行卡、微信账号、支付宝账号给上线“阿文”（身份不明）接收、转移涉案资金，并从中牟取非法利益。2021年5月6日至7日，江阴市陆某被他人网上裸聊敲诈勒索，其中人民币55000元转入陈某的建设银行卡后转出。

【案件焦点】

被告人侍某某系在判决宣告以后，假释裁定以前发现漏罪，但在假释考验

期限内被采取刑事强制措施，是否仍应当先判决撤销假释后再进行数罪并罚。

【法院裁判要旨】

江苏省江阴市人民法院经审理认为：被告人侍某某伙同他人在境外成立电信诈骗组织，一年内赴境外电信诈骗窝点超过三十日，从事针对中国境内居民的电信诈骗活动，属有其他严重情节，其行为确已构成诈骗罪。被告人侍某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，自愿认罪认罚，能够退出违法所得，依法予以从轻处罚。被告人侍某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前（在假释考验期限内）被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销假释，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。据此，判决如下：

一、撤销浙江省衢州市中级人民法院（2022）浙08刑更3411号对被告人侍某某予以假释的刑事裁定；

二、被告人侍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元，连同前罪所判处的有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币12万元；

三、扣押在案的被告人侍某某自愿退出的违法所得人民币3万元，予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在错综复杂的司法实践中，侦查过程是循序渐进的，侦查机关从锁定犯罪嫌疑人到实际对嫌疑人采取刑事强制措施之间往往存在一定的时间间隔，尤其是对于服刑人员的漏罪，经常会出现其刑满释放当天对其采取刑事强制措施的情况。虽然根据《中华人民共和国刑法》第八十六条第二款规定，在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他

罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。对于被假释的犯罪分子

